

0001136-46.2022.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Ademais, a prova dos autos indica que fazia o tráfico com certa frequência e de droga de fácil disseminação e com alto poder de vício ("crack"). Tal circunstância impede a aplicação do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico de drogas. Liberdade Provisória: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001136-46.2022.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001136-46.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - EM5274-1/2022 - Delegacia do Plantão Policial de Avaré - SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN APARECIDO CAETANO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

JEAN APARECIDO CAETANO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 21h30min, na rua Arlindo Castagnaro, nº161, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 69 (sessenta e nove) porções (pedras) de COCAÍNA ("CRACK"), com peso bruto de 5,86 g (cinco gramas e oitocentos e sessenta miligramas), droga essa que determina dependência física e psíquica (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação provisória de fls. 09/12, fotografias de fls. 13/14 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 109/112). Consta ainda , que nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, o denunciado

deteriorou a viatura policial, automóvel CHEV?TRAILBLAZER LT D4A, ano/modelo 2015/2016, placas FZP6298, chassi 9BG156FK0GC414379, pertencente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme laudo de perícia para constatação de danos que será oportunamente juntado.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do Inquérito Policial às fls. 01/52. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 66/68). Mandado de prisão cumprido a fls.94/95. Devidamente notificado (fls. 188), o réu apresentou Defesa Prévia (fls. 151/157). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2022, oportunidade em que também houve a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 163/165). Em audiência, foram ouvidas quatro testemunhas em comum, uma testemunha de Defesa e o réu interrogado (fls. 191/192 e gravações audiovisuais).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e, ao final, pugnou pela procedência da ação a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls.194/202). A douta defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e com relação ao crime de dano ao patrimônio pleiteou pela absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso III, do CCP. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pelo pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime menos gravoso (fls. 207/215).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

Segundo a inicial acusatória, "no tempo e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, quando foi surpreendido por policiais militares, bem como, deteriorou a viatura policial automóvel CHEV/TRAILBLAZER LT D4A, ano/modelo 2015/2016, placas FZP6298. Conforme apurado, na data dos fatos, policiais militares integrantes da Força Tática da Polícia Militar de Avaré/SP participava de operação realizada no município de Cerqueira César, quando avistaram o denunciado, que ao perceber que seria abordado, dispensou algo. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, vistoriado o local em que o denunciado dispensou o objeto, foi encontrado um frasco plástico com 69 (sessenta e nove) pedras de "Crack", drogas que o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros. Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado JEAN, que jogou o seu aparelho celular no chão e tentou fugir, sendo contido, momento em que familiares e populares geraram um tumulto, arremessando pedras na viatura policial e utilizando 02 (dois) cães da raça Pitbull. Prontamente, o denunciado foi colocado no guarda-presos e a Equipe deixou o local. Durante o trajeto para o plantão policial de Avaré/SP, o denunciado JEAN deteriorou a viatura policial, automóvel CHEV/TRAILBLAAZER LTD4A, ano/modelo 2015/2016, placas FZP6298, com chutes no compartimento de presos, danificando o guarda-presos e uma caixa para ferramentas. Após danificar o guarda-presos, que abriu, o acusado JEAN tentou saltar da viatura policial e fugir, sendo novamente contido. Anote-se que a natureza e a quantidade de droga apreendida, isto é, 69 (sessenta e nove) porções (pedras) de COCAÍNA ("CRACK") com peso bruto de 5,86g e às condições em que se desenvolveu a ação e as demais circunstâncias do caso apontam, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito. ".

Com efeito, ao ver deste juízo, tal versão restou comprovada devendo, pois, ser julgada procedente a ação penal.

A materialidade dos delitos restou configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência a fls. 03/06, auto de exibição e apreensão a fls. 07, laudo de constatação provisória dos entorpecentes a fls.09/14, laudo toxicológico definitivo a fls. 97/100 e 109/112, laudo pericial do veículo a fls. 136/142, bem como por toda prova oral produzida.

A autoria também é certa e indubitavelmente recai sobre o réu.

O policial militar Raphael Fernandes Borges, em juízo, disse " que estavam em patrulhamento no local onde ocorreram os fatos, momento em que visualizaram o

acusado descendo em sentido contrário e dispensando alguma coisa no chão. Realizaram a abordagem e procederam a busca pessoal. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Retornaram ao local aonde o acusado havia arremessado algo ao solo e encontraram um invólucro contendo entorpecente. Com isso, o réu ficou agitado, jogou o celular no chão, tentando fugir em direção a sua residência, gritando e chamando ajuda da vizinhança. Iniciou-se um tumulto com várias pessoas arremessando objetos. Colocaram-no na viatura, a qual o acusado danificou, tentando se evadir. O acusado quebrou a parte plástica do compartimento".

O policial militar Alessandro Batista da Silva, sob o crivo do contraditório, reprisou a assertiva de seu colega ressaltando " que foi ele quem encontrou o entorpecente. Relatou que viu o réu arremessando alguma coisa no chão. Disse que o acusado estourou o guarda preso da viatura para empreender fuga e amassou alguns lugares na viatura".

Marcus Vinicius de Araújo, policial militar, relatou que "realizavam patrulhamento quando viram o réu jogando alguma coisa no chão. Seu colega de farda Batista, encontrou o entorpecente quando estava revistando o local em que haviam visto o acusado dispensar alguma coisa ao solo. Contou que o réu estava exaltado e que tentava fugir. Disse que o acusado danificou a viatura, para conseguir fugir."

O policial militar, Júlio Miranda, disse que " foram para Cerqueira César participar de uma operação. Relatou que viram o acusado caminhando na via pública, quando este dispensou algo no chão. Realizaram a abordagem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. O colega de farda Batista ao refazer o trajeto em que viram o réu dispensar algo, localizou o entorpecente. Disse que o réu estava muito agressivo e incitava a comunidade. Relatou que ele tentou entrar em sua casa, local onde saíram dois cães para atacar a equipe. Além disso, vieram várias pessoas atirando paus e pedras. Disse que tiveram que utilizar a munição de impacto controlado. Quando o colocaram na viatura, este a danificou para tentar fugir. "

A testemunha de defesa Moisés Ferreira Rodrigues disse que presenciou a prisão do acusado. Relatou que o policial disse que ele seria liberado. Disse que o acusado ficou agressivo por causa dos cães. Afirmou que os cães são da raça pitbull, entretanto, são dóceis. "

O réu Jean Aparecido Caetano, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que "a droga encontrada não era de sua propriedade, e que no dia dos fatos havia ido até a residência de seu irmão para assistir a um jogo. Negou que tenha danificado a viatura. Disse que não conhecia os policiais."

Pois bem, a análise minuciosa do conjunto probatório amealhado em Juízo, em cotejo com as provas trazidas na fase policial, formam a firme convicção acerca da responsabilidade criminal do réu, impondo-se a condenação.

Com efeito, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais, além da prova da materialidade.

Nesse contexto, a versão do acusado além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação, não havendo, pois, qualquer razão para desacreditá-los.

Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (69 porções de crack) e do modo pelo qual estava acondicionada- em porções individuais a facilitar a comercialização e disseminação da droga.

Assim, a inocência invocada pelo réu não tem amparo das provas coligidas, pois não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregar a droga apreendida ao consumo de terceiros, vez que a quantidade e diversidade de droga apreendida são incompatíveis com o uso momentâneo. Nesse contexto, a versão do réu, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório

encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação. Neste diapasão, os depoimentos dos policiais foram absolutamente coerentes e bastaram à comprovação dos fatos, por não haver na hipótese qualquer contradição ou indicio de que tenham faltado com a verdade para incriminar falsamente a ré. Assim, sua negativa de autoria nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade. Soma-se a isto o fato de que a Folha de Antecedentes do réu (fls.55/57) e certidões de fls. 58/60 revelam seu envolvimento frequente com o crime, inclusive, com condenação anterior pelo mesmo crime em testilha possuindo, pois, má conduta social e inclinação para a prática delitiva.

Por outro lado, os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente e linear, descrevendo a ocorrência de forma idêntica ao quanto narrado em fase policial, sendo certo que os depoimentos dos agentes da Lei, sejam civis, militares, ou mesmo guardas municipais, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

E também não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade no depoimento de tais agentes, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-lo, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos milicianos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente a ré ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.)

Por derradeiro, observo que para a caracterização do crime em questão, não se exige a venda propriamente dita do entorpecente, pois o tipo penal inserto no artigo 33 da lei antidrogas fez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "ter em depósito" e "trazer consigo". Dessa maneira, basta a conduta de trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, diga-se mais uma vez, pela quantidade de droga apreendida (69 porções de crack), tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Confira-se:

"Anoto, ainda, que para configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas imputado aos réus, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que os agentes tragam consigo, tenham em depósito ou guardem a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512)" (9174718-08.2009.8.26.0000, Rel. Marco Antonio Marques Maia, 6ª Câmara de Direito Criminal, 17/09/2009)" (grifo nosso)

...

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663)

(grifo nosso)

Em relação ao delito de dano qualificado, entendo que as provas carreadas aos autos, efetivamente, comprovaram sua ocorrência. Os policiais foram uníssonos em afirmar que, no momento da abordagem, o réu tentou empreender fuga e para isso danificou a viatura.

Ora, não vejo motivos para uma acusação falsa por parte dos policiais, eis que não teriam qualquer interesse em, aleatoriamente, motivados por vingança ou perseguição, enquanto no exercício de suas profissões, prejudicarem o réu com acusações infundadas justamente, porque têm como função, salvaguardar a ordem pública. Além disso, o laudo pericial e as fotografias de fls. 136/142 constatarem os danos causados na viatura policial. Portanto, restou comprovado que foi o réu quem danificou a viatura, o qual pertence ao patrimônio público.

Cumprasse assinalar que o tipo não exige qualquer elemento subjetivo específico. O simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica vontade de causar prejuízo, logo, abrangido pelo dolo. Nesse sentido:

"Apelação. Crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação quanto ao crime de dano qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. O crime de dano não exige o dolo específico, bastando que o agente tenha consciência e vontade de realizar a conduta que produzirá uma lesão ao patrimônio de outrem. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 0004948-72.2016.8.26.0309; Rel. Laerte Marrone; 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 14/03/2019) (sem grifos no original).

"APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, CP) – Pretendida absolvição por ausência de comprovação de dolo – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas bem delineadas durante a instrução – Prova oral corroborada com outros elementos de convicção – Dolo evidenciado na voluntariedade da acusada de realizar a conduta de deteriorar patrimônio público, sendo irrelevante a sua motivação para a configuração do crime – Condenação mantida – Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos corretamente impostos – Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 0007252-40.2015.8.26.0451; Rel. Camilo Léllis; 4ª Câmara de Direito Criminal; j. 29/01/2019) (sem grifos no original).

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução. Assim, de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JEAN APARECIDO CAETANO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em concurso material. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes do réu (F.A. e certidões a fls. 55/60), fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (certidão - fls.58). Portanto, majoro em 1/6 a pena anteriormente aplicada, fixando em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. Na terceira fase, muito embora não exista nenhuma notícia e mesmo prova nos autos de que o réu pertencia a alguma associação criminosa, entendo que a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls.58) revela a conduta voltada à prática de atividades criminosas. Ademais, a prova dos autos indica que fazia o tráfico com certa frequência e de droga de fácil disseminação e com alto poder de vício ("crack"). Tal circunstância impede a aplicação do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico

de drogas. Liberdade Provisória: inadmissibilidade. Decisão que manteve a prisão. Participação em organização voltada para o tráfico de entorpecentes e grande quantidade de droga apreendida: circunstâncias suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06 e de substituição da pena: improcedência. Redução da pena inviável na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...]" (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12 – destaquei do original). Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Vertente ao crime de dano qualificado, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes do réu (F.A. e certidões a fls. 55/60), fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (certidão - fls.58). Portanto, majoro em 1/6 a pena anteriormente aplicada, fixando em 07 meses de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena, portanto, torno definitiva a pena anteriormente aplicada. Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Diante do concurso material entre todos os delitos, fixo em definitivo a pena a cumprir em 05 (CINCO) E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL E 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública.

É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal

possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciosos para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Cerqueira César.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Ademais, o réu foi preso preventivamente e permaneceu recolhido por todo o processo e não seria razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda que diante do regime imposto pela lei e do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, que deve ser exemplarmente punida. Recomende-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome do réu/condenado recorrente, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação dele, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento

do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei. P.I.C.

Cerqueira Cesar, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA